

<입문-제1장 개설.제1절 개요>

I. 사법(私法) : 민법, 상법 등) 적용

1. 사법 적용의 영역

- 사법은 사인(私人) 상호 간의 법률 관계를 규율하는 법으로서, 대등한 당사자 간의 자유로운 의사에 따른 법률 행위를 기본 전제로 한다. 민법은 재산 관계와 가족 관계 등 일반적인 사법 관계를 규율하며, 상법은 영리 목적의 상행위 및 회사 등 특별한 사법 관계를 규율한다. 행정 영역에서도 국가나 지방자치단체와 같은 행정주체가 사인의 지위에서 활동하는 경우, 그 법률 관계에는 사법이 적용된다. 이는 행정주체의 활동 중 공익 실현이라는 우월적 지위가 인정되지 않는 비권력적 활동에 해당한다.

2. 사법 적용의 구체적 사례

(1) 행정주체의 재산 행위

- 행정주체가 행정 목적을 달성하기 위해 필요한 물품을 구매하거나, 청사 부지를 확보하기 위해 사유 재산을 매매 또는 임대하는 행위는 사법상의 매매 또는 임대차 계약에 해당한다. 이 경우 행정주체는 매도인 또는 임대인으로서 민법의 규율을 받는다. 또한, 행정주체가 국유 재산 중 일반 재산(구 잡종 재산)을 대부(貸付)하거나 매각하는 행위 역시 사법 관계로 본다. 이 경우 행정주체는 공권력을 행사하는 것이 아니라 일반 사인과 같이 대등한 당사자로서 법률 행위를 한다.

(2) 공법인의 사법상 활동

- 공법인인 공기업이나 공단이 영리 목적으로 수행하는 수익 사업이나, 직원 채용 시 근로계약을 체결하는 행위는 사법 관계에 해당한다. 특히, 공법인이 일반 사업자와 같이 물품 공급 계약을 체결하거나 용역을 제공받는 경우에도 상법이나 민법이 적용된다.

3. 사법 적용 시 법적 쟁송 수단

- 행정주체가 사인으로서 사법상 계약을 체결하고 이행하는 과정에서 분쟁이 발생하면, 이는 민사 소송의 대상이 된다. 예를 들어 행정주체가 체결한 물품 구매 계약의 대금 지급을 거부하는 경우, 상대방 사인은 대금 청구의 민사 소송을 제기해야 한다. 이러한 사법 관계에서는 행정법의 일반 원칙(비례의 원칙, 평등의 원칙 등)이 직접적으로 적용되지 않으며, 민법상의 원칙(신의성실의 원칙, 계약 자유의 원칙 등)이 우선 적용된다.

II. 행정법 적용

1. 행정법 적용의 영역

- 행정법은 행정조직, 작용, 구제 등 공행정(公行政)에 관한 공법의 총체이다. 행정법은 공익 실현을 목적으로 하며, 행정주체가 우월적 지위에서 공권력을 행사하여 사인에게 법적 효과를 발생시키는 권력적 작용(행정 처분)에 주로 적용된다. 이는 행정주체가 국가 또는 지방자치단체의 공적 기능을 수행할 때 성립하는 공법 관계이다.

2. 공법 관계와 사법 관계의 구별 기준

(1) 당사자 기준설

- 법률 관계의 당사자 중 한쪽 당사자가 행정주체이면 공법 관계로, 양쪽 당사자가 사인이거나 행정주체가 사인의 지위에 있으면 사법 관계로 보는 견해이다. 그러나 행정주체가 당사자인 경우에도 사법 관계가 성립할 수 있어 불완전하다.

(2) 목적 기준설

- 법률 관계가 공익 실현을 목적으로 하면 공법 관계로, 사익 보호를 목적으로 하면 사법 관계로 보는 견해이다. 그러나 공익과 사익을 명확히 구분하기 어려워 적용에 한계가 있다.

(3) 성질 기준설(권력성 기준설)

- 법률 관계의 성질이 공권력 행사를 포함하는 상하 관계(우월적 지위)이면 공법 관계로, 대등한 관계이면 사법 관계로 보는 견해이다. 판례는 주로 이 권력성을 중요한 기준으로 삼아 행정주체가 일방적으로 법적 효과를 발생시키는지를 본다.

(4) 종속성 기준설

- 해당 법률 관계가 행정법규에 의해 규율되면 공법 관계로, 사법법규에 의해 규율되면 사법 관계로 보는 견해이다. 판례는 대체로 법률 관계를 규율하는 근거 법규의 성격을 가장 주요한 판단 기준으로 삼는다. 예를 들어 공무원 임용 행위는 국가공무원법에 근거하므로 공법 관계이다.

3. 행정법 적용 시 법적 쟁송 수단

- 행정법이 적용되는 공법 관계에서 행정주체의 위법한 공권력 행사로 인해 사인의 권익이 침해되면, 이는 행정쟁송의 대상이 된다. 행정쟁송에는 행정심판과 행정소송이 있으며, 사인은 이를 통해 행정작용의 위법성을 다투고 자신의 권익을 구제받는다.

III. 행정작용 개요

1. 행정작용의 개념

- 행정작용이란 행정주체가 공익 실현이라는 행정 목적을 달성하기 위해 구체적인 사실에 대해 행하는 일체의 활동을 의미한다. 행정작용은 행정조직이 수행하는 공권력적, 비권력적 활동을 모두 포괄하는 광범위한 개념이다.

2. 행정작용의 주요 유형

(1) 행정행위

① 개념

- 행정청이 구체적 사실에 대한 법 집행으로서 행하는 권력적 단독 행위이다. 국민의 권리·의무에 직접적인 변동을 초래하며, 가장 대표적인 행정작용이다. 행정소송의 대상이 되는 처분의 핵심을 이룬다. (예 : 영업 허가, 과세 처분, 공무원 징계)

② 특징

- 공정력이 인정되어 설령 위법하더라도 권한 있는 기관(법원)에 의해 취소되기 전까지는 일단 유효한 것으로 통용된다.

(2) 행정입법

① 개념

- 행정기관이 법규 사항에 관해 일반적·추상적인 규율을 정립하는 작용이다. 법규명령과 행정규칙으로 나뉜다. 법규명령은 대외적 구속력을 가져 국민의 권리·의무에 영향을 미친다.

② 특징

- 국가가 제정한 법률의 세부 사항을 보충하거나 집행을 위해 제정된다. 행정소송의 직접적인 대상은 될 수 없으나, 집행 행위(처분)의 위법성 판단 시 간접적으로 다루어진다.

(3) 행정계획

① 개념

- 미래의 일정한 목표를 설정하고 이를 달성하기 위해 수단을 종합적·조직적으로 조정·결정하는 활동 또는 그 결과다. (예 : 도시 기본 계획, 환경보전 계획)

② 특징

- 구속적 행정 계획은 처분성이 인정되어 행정쟁송의 대상이 되기도 하며, 계획 재량의 문제가 발생한다.

(4) 행정주체의 계약

① 개념

- 행정주체가 사인과 대등한 지위에서 합의를 통해 법적 효과를 발생시키는 작용이다. 행정주체의 사법상 계약과 공법상 계약을 포함하며, 공법상 계약은 행정 목적을 위한 것이나 권력 행사를 수반하지 않는다. (예 : 공무원 채용 계약)

② 특징

- 비권력적이므로 공정력과 같은 특수한 효력은 인정되지 않으며, 분쟁 발생 시 민사소송 또는 당사자소송(공법상 계약의 경우)의 대상이 된다.

IV. 행정쟁송 개요

1. 행정쟁송의 개념

- 행정쟁송이란 행정작용의 위법 또는 부당으로 인해 권익을 침해당한 국민이 행정주체를 상대로 행정작용의 취소, 변경, 무효 확인 등을 구하는 법적 구제 절차를 통칭한다. 이는 행정의 자율적 통제와 사법적 통제를 통해 국민의 권익을 보호하고 행정의 적법성을 확보하는 데 목적이 있다.

2. 행정쟁송의 유형

(1) 행정심판

① 개념

- 행정심판위원회 등 행정기관(행정부)이 심리·재결하는 행정상의 쟁송 절차이다. 처분의 위법성뿐만 아니라 부당성까지 다룰 수 있으며, 간이·신속한 구제를 목적으로 한다.

② 특징

- 행정소송을 제기하기 위한 필수적 절차인 경우도 있으며(필요적 행정심판전치주의), 행정주체 스스로 위법·부당한 행정작용을 시정할 기회를 제공한다.

(2) 행정소송

① 개념

- 법원(사법부)이 심리·판결하는 사법적 쟁송 절차이다. 처분 등의 위법성만을 다룰 수 있으며, 공정하고 최종적인 사법 통제를 통해 국민의 권리를 구제한다.

② 유형

- 항고소송(취소소송, 무효등 확인소송, 부작위위법확인소송), 당사자소송(공법상 계약이나 법률 관계의 다툼), 민중소송, 기관소송 등으로 분류된다. 취소소송이 가장 대표적인 형태이다.

3. 행정쟁송의 기능

(1) 국민의 권익 구제

- 위법하거나 부당한 행정작용으로 인해 침해된 국민의 권리를 회복시키고 손해를 전보함으로써 개인적 권리 구제를 실현한다.

(2) 행정의 적법성 확보(법치행정의 실현)

- 법원이나 행정심판위원회의 심리를 통해 행정기관의 법규 준수를 강제하고, 위법한 행정 관행을 시정함으로써 법치 행정의 원리를 확립한다.

(3) 행정작용의 형성

- 쟁송 결과에 따라 행정기관은 유사 사건에 대한 처리 기준을 재정립하게 되므로, 미래의 행정작용을 합법적이고 합리적으로 형성하는 데 기여한다.

V. 결론

- 행정법은 공익 실현을 목적으로 하는 행정주체의 우월적 공권력 행사를 규율하지만, 행정주체가 사인의 지위에서 활동하는 재산 행위 등에는 사법(민법, 상법)이 적용된다. 행정작용은 행정행위(처분), 행정입법, 공법상 계약 등 다양한 형태로 나타나며, 이 중 처분의 위법 또는 부당으로 국민의 권익이 침해되면 행정심판과 행정소송으로 구성된 행정쟁송을 통해 사법적 통제와 권익 구제를 실현한다. 행정쟁송은 국민의 권리 보호와 행정의 적법성 확보라는 이중적 기능을 수행하며 법치 행정의 원리를 구현한다.